

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS XIII

TEXTO CONSTITUCIONAL

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

“No processo” → cível, penal e administrativo.

ATENÇÃO

Neste ponto, a CF indicou menos do que deveria, porque existem **provas ilícitas e provas ilegítimas** (diferenciação doutrinária).

PROVAS ILÍCITAS

- **Diferença entre ilícitas e ilegítimas.**
 - Ilícitas – violam o direito material.
 - Ilegítimas – violam o direito processual.
 - **Atenção:** em uma prova de direito processual, tal diferença é bastante relevante. Mas, no contexto do constitucional, nem tanto, pois tudo se configura como prova imprestável.
- **Teoria dos frutos da árvore envenenada.**
 - Direito norte-americano – “*Fruit of the poisonous tree*”.
 - Se a prova está contaminada, aquelas que derivam dela também estarão. Ou seja, se a árvore está contaminada, os seus frutos serão imprestáveis.
 - Direito brasileiro – isso pode aparecer como ilicitude por derivação ou frutos da árvore envenenada.
 - Exemplo:
 - Prova A → interceptação telefônica sem autorização judicial – prova ilícita.
 - A partir dessa interceptação, foi pedido, ao juiz, uma nova quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Sendo que, agora, existe a autorização judicial.
 - Esta segunda prova é válida ou não? Não, porque a segunda prova veio da prova ilícita.



5m

ANOTAÇÕES

- **Cuidado:** o fato de existir uma prova ilícita no processo, por si só, não contamina o processo todo.
- Exemplo:
 - Prova A – ilícita.
 - Prova B – veio da A, logo não é válida.
 - Prova C – testemunho de várias pessoas, com contraditório e ampla defesa, no devido processo legal. Ou seja, a prova C é válida.
 - Mais do que isso, a prova C é independente → teoria da fonte ou da prova independente (“*independent source*”).

- **Acesso a conversas no WhatsApp.**

- Mutação constitucional → mudança na interpretação da norma, sem alterar o texto.
- Exemplo: mandado de injunção → mudança da jurisprudência do STF, em relação ao mandado de injunção, em 2007.
- 2012 → STF julgando sobre acessar o celular de um indivíduo.
 - A discussão era se precisava de autorização judicial para acessar o celular.
 - Na época, o Ministro Gilmar Mendes indicou que não.
 - Porém, de 2012 para cá, os celulares mudaram muito. Atualmente, um celular é, basicamente, um computador e possui todas as informações de um indivíduo → os dados telemáticos.
 - Sendo assim, o STF e o próprio Gilmar Mendes mudaram de entendimento → é preciso autorização judicial para ter acesso a conversas do WhatsApp. Sem autorização judicial, a prova será ilícita.

- **Encontro fortuito de provas ou crime achado (fenômeno da serendipidade).**

Obs.: observe o exemplo: se tem autorização judicial para ouvir o traficante A e o traficante C.

Porém, de repente, entra nas comunicações o indivíduo B.

Para o traficante A e C → existe autorização judicial para condená-los.

Mas e o indivíduo B? Não tem autorização judicial, mas também é possível condená-lo.

Perceba que, neste caso, ocorreu uma ampliação no número de investigados/suspeitos.

Sendo assim, aconteceu um encontro fortuito subjetivo.



10m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

- Encontro fortuito de provas ou crime achado:
 - Ampliação de investigados → encontro fortuito subjetivo.
 - Ampliação de crimes → encontro fortuito objetivo.
- **Gravação clandestina: conceito e (in)admissibilidade da prova.**
 - **Regra:** a gravação clandestina é válida, lícita, regular.
 - Perceba que uma pessoa pode gravar as conversas sem a outra pessoa saber.
 - Agora, é possível usar uma gravação clandestina para acusar alguém? Em regra, sim.
 - Exemplo: Operação Caixa de Pandora em Brasília. Nesta operação, o Durval Barbosa – o relator – gravou diversas figuras envolvidas no escândalo.
 - Então, definição de gravação clandestina → quando um dos interlocutores grava sem o conhecimento e sem o consentimento do outro.
 - **Exceção:** não pode usar gravação clandestina quando for conversa informal do policial com o suspeito.
 - Lembre-se de que o acusado tem o direito de ficar calado.
 - E tem a hora de falar, se quiser falar – o interrogatório.
 - Sendo assim, não se pode gravar conversa informal para prejudicar o réu.

Obs.: Espelhamento de WhatsApp → não pode.

Chip no celular do bandido → não pode.

Veja que se a prova derivar do computador da polícia, que está espelhando a conversa, não vale, porque não se sabe de onde a conversa saiu, quem apagou, quem escreveu etc.

PROVAS ILÍCITAS

Hipóteses de admissão:

- Meio de defesa.
 - Ou seja, se for usada na defesa, pode usar a prova ilícita.
 - **Cuidado:** não pode usar a prova ilícita se ela for a única para acusar.

ANOTAÇÕES



25m

- Teoria da descoberta inevitável.
 - Possibilidade de condenar alguém, usando provas ilícitas, se inevitavelmente a polícia chegasse às mesmas provas por meios lícitos.
- Teoria da mancha purgada ou diluída.
- Teoria da fonte ou prova independente.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
